

1502409-78.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502409-78.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502409-78.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2331352/2021 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21793137 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2941/21/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2331352 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS e LEONILSON FERNANDO DA SILVA MORAES, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, porque no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 11h50min, na Rua Tietê, nº 199, bairro Rudge Ramos, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente

ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 200 metros de fios e cabos elétricos, avaliados em R\$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes à vítima José Roberto Souza.

Segundo se apurou, os acusados, imbuídos de ânimo de assenhoramento definitivo, ajustaram-se para a prática de um furto.

Para tanto, nas circunstâncias acima mencionadas, os acusados se dirigiram a um galpão, estabelecido no local dos fatos, levando com eles as ferramentas necessárias à prática do delito, como dois alicates e uma faca.

Assim, aproveitando-se da aparente falta de vigilância e da ausência de pessoas no local, os acusados arrombaram a porta de ferro que dá acesso ao imóvel, logrando êxito em adentrar em seu interior.

Os acusados, então, subtraíram peças e cabos elétricos, utilizando as ferramentas para a retirada de tais bens.

Entretanto, após a subtração, a testemunha Kleber Leal Silva os surpreendeu saindo do galpão, cuja porta estava arrombada, na posse de mochilas.

Imediatamente, a testemunha os abordou e os questionou, determinando que eles aguardassem o proprietário do estabelecimento, o qual havia sido informado acerca dos fatos.

Instantes depois, o ofendido José Roberto chegou no galpão, sendo acionada a Polícia Militar.

Em revista pessoal, foram apreendidas em poder dos acusados as ferramentas (dois alicates e uma faca) utilizadas para cortar os cabos.

No interior das mochilas foram localizadas as peças e cabos elétricos, reconhecidos pela vítima como sendo do imóvel.

Destarte, os acusados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Acompanhada por inquérito policial (págs.04/77), a denúncia foi recebida (págs.98/102). Regularmente citados (págs. 116 e 118), os réus apresentaram respostas à acusação (págs. 155 e 159). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.160/161), em instrução foram ouvidos a vítima e duas testemunhas comuns, interrogando-se os réus. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Mariany Viana de Paula.

Em debates, a acusação requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia; ao passo que a defesa postula a absolvição por negativa de autoria ou, ainda, por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito está demonstrada nos autos de exibição, apreensão e entrega de págs. 21/22 (cabos); exibição e apreensão de pág. 23 (ferramentas usadas no crime) e de avaliação a pág. 24, bem como nos laudos periciais juntados às págs. 110/114 (ferramentas usadas no crime) e 177/183 (local dos fatos).

A existência do crime também vem comprovada nas declarações da vítima José Roberto Souza:

O imóvel pertence à sua irmã, mas é o administrador e responsável de fato. O galpão estava desocupado, disponível para locação, e permanecia trancado. Não estava abandonado, sendo que os vizinhos o vigiavam. Na data do fato, na manhã daquela segunda-feira, recebeu ligação telefônica de KLEBER. O vizinho noticiou que a porta de ferro que dá acesso ao imóvel havia sido arrombada. Imediatamente, dirigiu-se ao local.

Quando ali chegou os dois acusados estavam sentados na frente do galpão, contidos por KLEBER. O vizinho surpreendeu os dois rapazes saindo do imóvel pela porta arrombada, portando mochilas contendo os fios e cabos elétricos tirados do galpão, o qual encontrou destruído. Constatou que os indivíduos tinham levado vários objetos, dentre portas e janelas, durante o fim de semana.

Acionou a Polícia Militar. Enquanto aguardava a viatura, ingressou no imóvel para verificar o que tinha sido subtraído. Um dos rapazes (o réu RAFAEL) entrou no local e pediu que o liberasse, afirmando que outras pessoas também tinham ingressado no local para a prática de furto. Nesse momento, chegaram os policiais militares. Os agentes portavam alicates para corte de cabo e outras ferramentas, tendo sido encaminhados à Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante.

Em Juízo, a vítima reconheceu os réus Rafael e Leonilson, apontando-os, dentre outros indivíduos, como os autores do delito.

Manifesta a relevância probatória da palavra da vítima no delito de furto, principalmente quando descreve com firmeza a cena criminoso e reconhece o agente com igual certeza (RT 606/357).

Nessa linha: "Palavra da vítima - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (RJDTACRIM VOLUME 18 - ABRIL/JUNHO 1993 - PÁGINA: 194 - RELATOR:- ORLANDO BASTOS) - grifei

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (págs. 09/10 e 11/12), em Juízo os réus ofertaram parcial confissão:

São moradores de rua e vivem do trabalho de reciclagem. Passavam pelo local, viram a porta do galpão aberta e ali ingressaram para usar crack e consumir álcool. O local estava aparentemente abandonado e visualizaram cabos elétricos pelo chão. As mochilas também estavam abandonadas no local e dentro delas colocaram os fios e cabos elétricos, deixando o local.

Não agiram com dolo de furto. Neste momento, foram surpreendidos pela testemunha Kleber e outro indivíduo, que efetuaram a detenção, chamando o proprietário.

Rafael acrescentou que buscou explicar o ocorrido ao proprietário do galpão, mas a Polícia Militar foi acionada.

A negativa de dolo ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução. Sob o crivo do contraditório, a testemunha Kleber L.Silva narrou os lances do crime praticado, espancando qualquer dúvida acerca da autoria:

Ocupa galpão situado na frente do local do crime. Na data do fato, por volta das 10h00 da segunda-feira, notou que a porta de ferro que dá acesso ao interior daquele imóvel havia sido arrombada. Ingressou no local e não localizou ninguém, embora tenha visualizado mochilas, fios e cabos elétricos no chão. Notadamente, vários objetos tinham sido subtraídos do interior do imóvel durante o fim de semana. Contatou o proprietário José para noticiar o ocorrido.

Instantes depois, outro vizinho visualizou quando os dois acusados saíam do galpão e o alertou. Nesse momento, abordou os acusados, que deixavam o local na posse de mochilas contendo os fios e cabos elétricos subtraídos.

Pouco depois, JOSÉ chegou ao local. O proprietário ingressou no imóvel para verificar o que havia sido subtraído e o acusado Rafael (com o qual tinha estudado) ali também ingressou para falar com ele.

Os policiais militares chegaram e encaminharam os acusados à Delegacia de Polícia. Foi constatado que os réus portavam ferramentas para a prática do delito, dentre eles um alicate de corte de cabo.

Ratificando a reconhecimento inicial, em Juízo a testemunha reconheceu os acusados como sendo os autores do crime, sem esboço de dúvida.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar DAnylo Moraes França informou, em relato coeso e harmônico com o anterior, informou os passos da diligência encetada na data dos fatos:

Realizava patrulhamento de rotina e recebeu a notícia de furto no galpão localizado na Rua Tietê, nº 189, Vila Vivaldi, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP, via

COPOM. Dirigiu-se ao local, onde os réus já tinham sido detidos pela testemunha Kleber. Os réus foram surpreendidos em ação, saindo do imóvel com mochilas contendo os cabos e fios elétricos.

Inquiridos, os agentes, que portavam ferramentas para a prática do delito, dentre elas alicate de corte, confessaram o crime e admitiram que, durante o fim de semana, tinha ingressado no imóvel para subtração de outros pertences, voltando na segunda-feira para levar o que faltava. Os réus não informaram que outras pessoas também tinham subtraído bens do galpão. Para ingressar no local, os agentes arrombaram a porta de ferro que dá acesso ao interior do galpão.

Não conhecia os acusados.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.199-p. 39.846).

E seus informes devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria.

Destaca-se que o imóvel não estava abandonado. Embora desocupado, aguardava locação fechado e com vigilância exercida por vizinhos. O aparente estado de abandono - retratado no laudo pericial referente ao local do fato - decorre da deterioração do imóvel causada pelos próprios furtadores, que levaram janelas, portas e forro, além dos fios e cabos elétricos.

E, ao contrário do ventilado pela defesa, o imóvel tem dono. A irmã de José, responsável pela administração do galpão. Comprovado que os agentes buscaram subtração coisa alheia móvel, é que basta para a condenação.

O crime de furto não ultrapassou a esfera da tentativa. Os réus foram surpreendidos pela testemunha Kleber quando saíam do galpão na posse dos bens que buscavam subtrair.

Dessa forma, por circunstância alheia à vontade dos acusados, não houve efetiva inversão da detenção em posse.

Não se pode acolher o pleito de atipicidade da conduta perpetrada, em virtude da aplicação do princípio da insignificância. Como se sabe, o princípio da insignificância não pode ser aplicado de maneira indiscriminada, sob pena de incentivo ao cometimento de delitos de pequena monta.

Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do aludido princípio, a saber:

(i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).

No presente caso, não se pode considerar que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva. Apesar de não se tratar de um furto de grande monta, a quantia subtraída apresenta valor considerável (R\$ 1.000,00 - pág. 24), notadamente se levada em conta a realidade econômica do país. Ademais, a falta de punição de pequenos crimes acarretaria exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de ilícitos, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor.

E há reprovabilidade da conduta dos réus.

Além do envolvimento pretérito em delitos da mesma natureza, os réus agiram com má-fé diferenciada, em comparsaria e arrombando o imóvel para subtração dos cabos elétricos.

Nesse sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BICICLETA. OBJETO DE VALOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação Criminal nº 0001169-38.2018.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - VOTO Nº 50.542 / FLS. 6/8 PEQUENO, PORÉM RELEVANTE. INAPLICABILIDADE

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A conduta perpetrada pelo agente não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela - tentativa de furto de uma bicicleta, avaliada em R\$90,00 -, não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido no §2º do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social. 4. Recurso provido para, afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau" (REsp. 828.181/RS; 2006/0046734-0; Relatora Ministra Laurita Vaz; 5ª Turma; j. 14/06/2007; DJ 06.08.2007, p. 654). Não incide a figura do furto privilegiado (CP, art.155, §2º), pois os réus, reincidentes em crime patrimonial, não preenchem os requisitos legais. Ao cabo da instrução, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes ficaram comprovadas.

O perito atestou no laudo pericial de págs. 177/183:

"O portão metálico que guarnecia a entrada do imóvel estava amolgado, os danos foram produzidos de fora para dentro, o batente do portão apresentava marcas de atritamento e amolgamento, danos produzidos de fora para dentro".

Os agentes admitiram a circunstância ao policial militar ainda no local do fato e confessaram que, durante o fim de semana, tinha estado no local para subtração de outros bens.

A comparsaria entre os acusados vem evidenciada pela forma de atuação, ou seja, em conjunto, com plena aderência de vontades e divisão de tarefas, cada qual fazendo sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo. Os acusados, previamente ajustados, ingressaram no imóvel da vítima e subtraíram cabos elétricos do local. Não se olvida a alegação de que os agentes são moradores de rua. Por si só, tal situação não configura estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não configura a discriminante. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida. De tal ônus o réu não se desincumbiu a contento.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade da acusado, muito menos que agira visando proteger-se de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente, não se desincumbindo, portanto, do ônus insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Eventual dificuldade financeira não autoriza, por si só, a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico,

tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

A declaração de que os agentes são usuários de crack também não leva à absolvição. Não há prova de que, durante a ação criminosa, estavam sob efeito de droga. Não obstante, ainda que a premissa fosse adotada como verdadeira, não teria o condão de afastar a culpabilidade dos réus.

Em Juízo, os réus não apresentaram qualquer indicativo que revelasse comprometimento da capacidade cognitiva em razão do uso de substâncias entorpecentes.

Pelo contrário, revelaram-se lúcidos, relatando a sua versão dos fatos de forma concatenada e segura.

Outrossim, presos desde dezembro p.p, os réus declararam que não mais consumiram droga e afastaram alteração comportamental ou de saúde, o que não se coaduna com o quadro de dependência química.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Des^a MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Dessarte, os acusados realizaram conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Analisados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 não são totalmente favoráveis aos réus.

De plano, porque se sobressai maior grau de censurabilidade na conduta praticada. Não se pode perder de vista a existência de duas qualificadoras, servindo uma para tal fim, funcionando a outra como circunstância judicial apta a demonstrar maior culpabilidade dos agentes. Além de atuar em comparsaria, os réus arrombaram o portão de ferro que dá acesso ao imóvel.

Não se trata de levar em conta apenas o número de qualificadoras, mas na medida em que configurada cada uma delas, acrescidas, sem sombra de dúvida a culpabilidade dos agentes torna-se mais intensa.

Um furto cometido com uma qualificadora não é igual a outro praticado com duas ou mais circunstâncias previstas no §4º do artigo 155 do Código Penal, sendo que nesta última situação o acusado deve ser apenado com mais rigor, sob pena de inobservância do princípio isonômico e da mais adequada individualização da pena em cada caso concreto. É maior a reprovabilidade da conduta do agente, justamente o que se vê patenteado nestes autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCENTE.

COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 2. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. Precedentes. 3. A presença de mais de uma qualificadora, malgrado não implique alteração da pena in abstrato, demanda maior resposta penal e, por consectário, a exasperação da reprimenda in concreto, em atendimento ao princípio da individualização da pena, restando apenas vedada a dupla valoração de uma mesma circunstância. (...) 8. Writ não conhecido. (HC 353.493/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

E não é só. Ambos os acusados têm condições subjetivas desfavoráveis.

RAFAEL ostenta 02 (duas) condenações anteriores e irrecorríveis por tráfico de entorpecentes (autos nº 0001028-17.2018.8.26.0537 - 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado 24/06/2019) e furto (autos nº 1501528-63.2019.8.26.0540 - 4ª Vara Criminal de Santo André. Trânsito em julgado: 17/05/2021, cf. certidão criminal de págs.33/37 e F.A de págs.38/45).

Reiterando a conduta em breve espaço de tempo, o réu demonstrou que faz da prática de crime patrimonial o seu meio de vida.

LEONILSON ostenta 05 (cinco) condenações anteriores e irrecorríveis por roubo (autos nº 0048480-83.2011.8.26.0564 - 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado: 24/11/2015. Extinção da pena pelo cumprimento em 08/08/2019); furto (autos nº 0001939-88.2016.8.26.0540 - 2ª Vara Criminal de São Caetano do Sul. Trânsito em julgado: 01/03/2017); furto (autos nº 0016187-02.2007.8.26.0564 - 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado: 18/01/2010. Pena extinta pelo cumprimento em 08/08/2019); furto (autos nº 0021328-65.2008.8.26.0564 - 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado: 05/05/2011, pena extinta 11/08/2021) e furto (autos nº 0019291-62.2008.8.26.0565 - 1ª Vara Criminal de São Caetano do Sul. Trânsito em julgado: 08/06/2009. Pena extinta pelo cumprimento em 08/08/2019, cf. certidão criminal de págs. 46/51 e folha de antecedentes de págs. 52/71).

Reiterando a conduta em breve espaço de tempo, e ainda cumprindo pena definitiva anterior em regime aberto, Leonilson demonstrou que o delito em apreço não cuidou de mero desvio na vida do acusado.

Assim, fixo a pena-base de cada acusado acima do mínimo legal, elevando-a em 1/4 para Rafael e 1/2 para Leonilson, o que perfaz, respectivamente, 02 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa e 03 anos de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa.

Os índices são proporcionais e adequados às circunstâncias acima ponderadas.

Os réus são reincidentes específicos (RAFAEL - autos nº 1502129-35.2020.8.26.0540 - 4ª Vara Criminal de Santo André. Trânsito em julgado: 17/05/2021. Pena extinta pelo cumprimento em 04/08/2021. LEONILSON - autos nº 1500005-16.2019.8.26.0540 - 1ª Vara Criminal de São Caetano do Sul. Trânsito em julgado: 18/02/2019. Pena por cumprir, cf. certidões criminais de págs. 33/37 e 46/51 e folhas de antecedentes de págs. 38/45 e 52/71).

Elevo a pena de cada réu em 1/6, fixando-a, respectivamente, em 02 anos e 11 meses de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa e 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Inexiste bis in idem pelo reconhecimento de antecedentes criminais na primeira etapa e da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, pois foram

consideradas condenações distintas.

Neste sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no RESp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019, v.u.).

Não incidem atenuantes.

Inexistem, outrossim, causas de aumento de pena.

Reconhecida a tentativa, pondero que os acusados foram surpreendidos quando já deixavam o imóvel, após arrombamento do portão de berro, corte de cabos elétricos e ocultação dos bens em mochilas. Quase completo o iter criminis percorrido, reduzo a reprimenda no patamar mínimo de 1/3, o que perfaz 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 09 dias-multa (Rafael) e 02 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa (Leonilson).

O valor do dia-multa, ante a aparente situação econômica dos acusados, será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento de pena, fixo para ambos os acusados o regime FECHADO.

É o adequado para a consecução das finalidades da sanção penal, considerada a prática ininterrupta de crimes (principalmente os patrimoniais), circunstância apta a demonstrar que os réus fazem da ação delitativa o meio vida, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumprе salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática REITERADA de crimes patrimoniais pelos réus, que ostentam diversas condenações anteriores e irrecorríveis e são reincidentes, denota conduta social inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade mais severa. Leonilson ainda cumpria reprimenda definitiva quando voltou a delinquir. Desse modo, a fixação de regime mais favorável ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes os requisitos legais, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a subtração de coisa alheia móvel.

A Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para permitir que o Juiz desconte na sentença o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas apresentadas pelos acusados, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária

do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar os réus:

a) RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, I (rompimento de obstáculo) e II (concurso de agentes) c.c. o artigo 14, II, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 09 dias-multa, no valor unitário mínimo.

b) LEONILSON FERNANDO DA SILVA MORAES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, I (rompimento de obstáculo) e II (concurso de agentes) c.c. o artigo 14, II, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Os réus responderam ao processo presos (conversão do flagrante em prisão preventiva às págs.79/82).

Mantenho a prisão preventiva dos acusados. Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nos depoimentos da vítima, da testemunha presencial e do policial militar nas duas etapas da persecução penal, bem como na presente condenação. O periculum libertatis vem consubstanciado nas desfavoráveis condições subjetivas dos acusados - réus reincidentes específicos, ostentam diversas condenações anteriores e irrecorríveis e adotaram a prática de crimes como meio de vida. Há fortes indícios de que, em liberdade, voltarão a delinquir, reiterando a conduta. Há que se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

As medidas cautelares não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, que é imprescindível para atendimento das finalidades da persecução penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, os réus não poderão apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomendem-se os acusados na prisão onde se encontram recolhidos.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

De imediato, não impugnados o laudo pericial (págs. 110/114), autorizo a destruição dos objetos apreendidos (pág. 23). Oficie-se à Autoridade competente.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeçam-se guia de execução definitiva.

Oficie-se ao TRE informando sobre a suspensão dos direitos políticos dos condenados, ao cartório Distribuidor e ao IIRGD.

Custas pelos réus, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do

artigo 98, §3º, do Código Penal.

P.I.C

São Bernardo do Campo, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA